

1500316-59.2022.8.26.0618
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio
Comarca: Taubaté
Foro: Foro de Taubaté
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/07/2022
... - Grifou-se).

Penal. Processo penal. Delito de tráfico de drogas (art. 33, "caput, da lei nº 11.343/2006). Sentença condenatória. Recursos do réu e do Ministério Público. 1) - Tráfico de drogas. Pena. A) [...] C) - causa de especial aumento (apelo 02). Prática de tráfico nas proximidades de instituição de ensino (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06). Tese ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
1ª Vara Criminal
PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N
CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070
FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1500316-59.2022.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500316-59.2022.8.26.0618
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor
Réu
Justiça Pública
Heberton Luiz do Prado
Réu Preso
Vistos.

Heberton Luiz do Prado foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de março de 2022, por volta de 00h25min, na rua Capitão Antônio Delgado Escobar, bairro Estiva, nas proximidades da Creche Municipal Miguel Ribas Branco, nesta cidade e comarca de Taubaté, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Descreve a denúncia que o réu, ao avistar a aproximação de guardas civis municipais, dispensou a sacola que trazia consigo e empreendeu fuga. Todavia, foi detido e a sacola recuperada, constatando-se em seu interior 27 porções de cocaína, acondicionadas em pequenos tubos plásticos. Ainda, nas vestes do réu foi localizada a quantia de R\$ 20,00, produto de venda de drogas (fls. 59/60).

Recebida a denúncia, em 24 de março de 2022 (fls. 61/64), o réu foi citado (fls. 86) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 100).

Saneado o processo (fls. 104/105) e assentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 110/111), realizou-se audiência de

instrução por teleconferência, mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, cujo registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 118/119).

Na oportunidade foram inquiridas as testemunhas do rol acusatório, comuns à defesa, e procedeu-se ao interrogatório do réu.

Seguiu-se a apresentação de alegações finais orais, em que o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu; o reconhecimento da agravante de reincidência, mas não da atenuante de confissão, dado que o réu se retratou em juízo; a aplicação da causa de aumento de pena pela proximidade do réu com o estabelecimento de ensino; que não seja aplicado o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante os maus antecedentes e a reincidência do réu; a cominação do regime inicial fechado de cumprimento de pena e o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Já a Defesa pugnou pela alteração da classificação típica da conduta, a fim de que o réu seja incursionado no art. 28, ou no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, pois há dúvidas sobre a destinação das drogas, havendo possibilidade de que seriam para uso próprio ou compartilhado. Subsidiariamente, para a hipótese de condenação, pleiteou seja a pena-base fixada no mínimo legal, pela pequena quantidade de drogas apreendidas e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecendo-se a reincidência, mas também a confissão, e afastando-se a causa especial de aumento de pena referida na denúncia porque a creche junto à qual o réu se encontrava estava fechada quando dos fatos, não havendo maximização do risco àqueles que frequentam o estabelecimento de ensino, nem facilitação do tráfico pela maior aglomeração de pessoas.

É o relatório.

Decido.

O réu está sendo acusado do crime de tráfico de drogas, com a majorante de pena por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino.

A respeito da conduta delitiva foram lavrados auto de prisão em flagrante delito (fls. 01) e boletim de ocorrência (fls. 02/05), e registrou-se a apreensão, em poder do réu, da quantia de R\$ 20,00 em dinheiro e de 27 invólucros que continham cocaína (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 15 e Fotografia a fls. 20).

Preliminarmente (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente a fls. 17/19) e definitivamente (Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 101/103) identificou-se que a droga apreendida em poder do réu, com massa líquida total de 10,04g, tratava-se, efetivamente, de cocaína, pois "foi DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, que se encontra descrita na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)".

A materialidade delitiva está bem comprovada.

Inquiridos quando da lavratura do flagrante, os guardas civis municipais Paulo César Florêncio e Eduardo Marcondes de Godoy narraram que se deslocavam entre dois prédios públicos e ao se aproximarem da Creche Municipal Miguel Ribas Branco avistaram um rapaz que, em atitude suspeita, tentou correr e dispensou um saquinho plástico contendo 27 pinos de cocaína. Ainda, presa na cintura, com o elástico da roupa íntima do réu, estava a quantia de R\$20,00 em dinheiro. Indagado, o réu disse que estava há três horas no local vendendo pinos de cocaína e que já havia sido preso outras vezes, por furto e tráfico de entorpecentes. Foi dada voz de prisão em flagrante ao réu e ele foi conduzido à delegacia (fls. 21 e 22, respectivamente).

Os mesmos guardas municipais civis apresentaram em juízo depoimentos uníssonos aos da fase policial e, em acréscimo, informaram que o réu estava encostado no muro da creche e, de acordo com o GM Paulo, a aproximadamente 10 metros do portão de entrada. Levava a sacola plástica nas mãos e a dispensou assim que avistou a viatura – o que foi visualizado pelos guardas – e tentou correr, sendo abordado a alguns metros da sacola dispensada. Segundo o GM Eduardo, o réu não conseguiu se deslocar rapidamente porque estava com o joelho machucado. Os fatos se deram por volta da meia-noite e meia, quando a creche não estava em funcionamento. O dinheiro localizado com o réu consistia em duas notas de R\$10,00. O réu não mencionou ser usuário de drogas. O GM Paulo já o conhecia anteriormente aos fatos porque estudaram juntos na mesma escola, mas nunca tiveram qualquer divergência, nem saberia dizer algo atual ao seu respeito. Por fim, o GM Eduardo disse que realizavam rondas rotineiras no local dos fatos, desconhecendo informação de que seja ponto de compra e venda de drogas.

Ao ser interrogado pela autoridade policial o réu confessou a prática delitiva e disse que estava vendendo a droga localizada em seu poder (fls. 06).

Em juízo, todavia, apresentou versão diversa. Assumiu a propriedade da droga, mas negou a prática do tráfico, sustentando que aquela seria destinada ao próprio consumo. Disse que reside próximo à creche e nas proximidades há um ponto de venda de drogas. Havia acabado de comprar a droga, a qual estava na cesta da sua bicicleta. Negou ter dispensado a droga ao solo. Estava parado em frente à creche quando foi abordado. Aguardava sua esposa que havia ido a uma adega para comprar bebidas, pois reuniriam amigos em sua casa. Usariam as drogas com os amigos. Disse para os guardas que era usuário de drogas, assim como o fez na delegacia. Negou ter-lhes informado que estava traficando. Negou ter confessado na fase policial que estava traficando. Trabalha na empresa “Marmoraria WK” e recebe R\$1.900,00/mês. Registra condenação criminal anterior porque era usuário de crack. Atualmente é usuário de cocaína. Não possui filhos. Não se recordou de ter estudado com um dos guardas. Negou problemas com os guardas durante a abordagem. Confirmou ter problema médico em seu joelho, em que inclusive realizou procedimento cirúrgico.

A traficância fora confessada pelo réu em duas oportunidades: aos guardas civis municipais, durante a abordagem, e diante da autoridade policial. Somente em juízo optou por alterar seu posicionamento, apresentando outra narrativa, de que estava parado em frente à creche aguardando a esposa que havia ido comprar bebidas alcóolicas, tendo adquirido os pinos de cocaína para o próprio consumo, que estavam na cesta de sua bicicleta.

A negativa de autoria do réu em juízo, inclusive de que não teria confessado a traficância anteriormente, não se sustenta. A autoridade policial não faria constar do termo de interrogatório algo substancialmente contrário àquilo que o réu teria dito, ou algo que ele não houvesse dito.

Os depoimentos dos guardas civis municipais foram uníssonos nas duas oportunidades em que ouvidos: avistaram o réu quando estava parado em frente ao muro da creche e visualizaram que ele dispensou a sacola que trazia consigo ao perceber a aproximação dos guardas. Estes afirmaram que a sacola foi localizada no chão, justamente porque fora dispensada, em inequívoca intenção do réu de não ser abordado na posse de drogas. Portanto, não estava na cestinha de qualquer bicicleta. Os guardas referiram que o réu tentou afastar-se a pé, tendo dificuldade para fazê-lo devido a algum problema no joelho, fato corroborado pelo réu, que inclusive mencionou ter realizado procedimento cirúrgico no joelho. Os guardas não notariam alguma dificuldade de deambulação se o réu estivesse de bicicleta. Não foi documentada a apreensão desse meio de transporte. A narrativa do réu não é provida de verossimilhança.

Se as drogas se destinavam ao consumo próprio, e o réu havia acabado de adquiri-

las, já poderia ter se dirigido à sua residência, situada nas proximidades, não havendo razão para sua permanência no local da abordagem. Carece de credibilidade sua narrativa de que numa quarta-feira, por volta de 00h25min - dia útil e durante a madrugada - o réu permitiria que sua esposa se deslocasse a um estabelecimento comercial - se é que haveria algum em funcionamento - para adquirir bebidas alcóolicas sem o seu acompanhamento, ficando apenas parado à sua espera, portando uma sacola com muitos pinos de cocaína, que segundo alegou, seriam consumidos com amigos que ainda iriam à sua casa. Note-se que tais fatos não foram mencionados no Boletim de Ocorrência, nem nos depoimentos dos guardas municipais, o que seria natural com o retorno da esposa do réu ao local em que ele a aguardava ou com alguma menção dele a respeito da sua pessoa, o que não ocorreu.

O réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar - embora com possibilidade - a alegação de que ofereceria drogas a amigos para consumo conjunto, sem o objetivo de lucro.

O réu era conhecido de um dos guardas municipais porquanto estudaram juntos na mesma escola, circunstância que o agente público não procurou esconder, ressaltando a inexistência de qualquer divergência entre eles. O próprio réu não se recordou de ter estudado com um dos guardas que realizou a sua abordagem. Outrossim, asseverou não ter havido qualquer intercorrência durante a abordagem. Assim sendo, não haveria motivos para que os guardas prejudicassem o réu de maneira intencional.

O réu trazia consigo 27 eppendorfs de cocaína, embalados e individualizados de forma típica do comércio ilícito de entorpecentes, além de duas notas trocadas de R\$10,00, ao que tudo indica produto da venda de drogas (fotografia a fls. 20). A pequena quantia em dinheiro, em cotejo com a alegação do réu de que já estava no local há cerca de três horas, não afasta a conclusão sobre a traficância, pois pode ser que o réu ainda não houvesse vendido quantidade significativa de porções - não se olvidando que os guardas referiram desconhecer que o local fosse ponto de tráfico, o que pode ser indicativo da incipiência da conduta e seu desconhecimento por terceiros - ou por ocultação de valores em espécie em algum esconderijo nas proximidades.

Da mesma forma, o alegado uso de entorpecentes pelo réu não descaracteriza a venda de drogas a terceiros, práticas que muitas vezes se complementam, incentivando o consumo até mesmo de quem faz o seu fornecimento.

Por outro lado, em que pese o delito tenha sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, há precedentes jurisprudenciais que entendem pela não incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06 quando o caso concreto assim o exige. A referida causa de aumento de pena visa inibir que o agente pratique crimes nas proximidades de determinados locais, ou neles próprios, de modo que impossibilitem maior fiscalização, dado o aglomerado de pessoas, além da maximização de riscos aos frequentadores do local e o seu maior grau de vulnerabilidade.

Contudo, o crime da hipótese em apreço foi cometido no início da madrugada, quando a creche estava fechada, não havendo razão para a punição com maior rigor, dada a ausência de transeuntes no local, inclusive de funcionários.

Nesse sentido, segue jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e outra, mais recente, do E. Tribunal de Justiça do Paraná:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PERPETRADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele

que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares. 2. Como, na espécie, não ficou evidenciado nenhum benefício advindo ao paciente com a prática do delito nas proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino - o ilícito foi perpetrado, tão somente, em um domingo, de madrugada - e se também não houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam a escola (alunos, pais, professores, funcionários em geral), deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante. 3. Ordem concedida, para afastar a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir a reprimenda do paciente para 3 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa." (STJ - HC: 451260 ES 2018/0121725-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018 - Grifou-se).

Penal. Processo penal. Delito de tráfico de drogas (art. 33, "caput, da lei nº 11.343/2006). Sentença condenatória. Recursos do réu e do Ministério Público. 1) - Tráfico de drogas. Pena. A) [...] C) - causa de especial aumento (apelo 02). Prática de tráfico nas proximidades de instituição de ensino (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06). Tese desacolhida. Prática delitiva no período em que a instituição de ensino estava fechada. Proximidade que, diante das circunstâncias do caso em apreço, não maximizou o risco inerente à prática da narcotraficância. Elemento meramente circunstancial. Precedentes. Pena mantida. [...] (TJPR - 4ª C.Criminal - 0016994-45.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 02.06.2022), (TJ-PR - APL: 00169944520208160014 Londrina 0016994-45.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 02/06/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2022 - Grifou-se).

Frente ao exposto, incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, bem como para a do art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06 (oferecimento de drogas para consumo em conjunto com pessoa de seu relacionamento, de forma eventual e sem o objetivo de lucro), deve o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas, comprovadas pelas provas produzidas, estas corroboradas pela confissão do réu quando da abordagem pelos guardas municipais e na fase policial.

Sendo caso de condenação, procedo à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

O réu não ostenta maus antecedentes para fins de recrudesimento das penas nesta fase de dosificação e não se afiguram de excepcional gravidade as circunstâncias e consequências do delito, já que embora estivesse o réu em poder de cocaína, substância entorpecente cujo efeito deletério sobre o organismo humano é muito mais drástico do que o de outras substâncias de uso proscrito no Brasil, a quantidade relativamente diminuta, de 10,04g, não justifica a fixação das penas-base acima dos mínimos legais, razões pelas quais, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e àquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo-as em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A Certidão de Distribuições Criminais e a Folha de Antecedentes relativas ao réu (fls. 65/68 e 69/74) comprovam múltiplas condenações do réu por crimes patrimoniais, especificamente pela prática de furto, quais sejam nos autos (i) nº 0015072-10.2014.8.26.0625 (2ª Vara Criminal de Taubaté, com trânsito em julgado em

17/04/2017 para o Ministério Público e em 24/05/2017 para a defesa); (ii) nº 0000351-19.2015.8.26.0625, da 1ª Vara Criminal Taubaté; (iii) nº 0001169-21.2017.8.26.0618, da 1ª Vara Criminal Taubaté; e (iv) 0005882-57.2013.8.26.0625, da 2ª Vara Criminal de Taubaté, tendo sido as penas desses três últimos processos somadas em 04.09.2019, nos autos de execução nº 0004474-45.2019.8.26.0520, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, sobrevivendo progressão para o regime aberto em 28/07/2020, até que o réu foi preso preventivamente em 10.03.2022, por estes autos, ou seja, estava cumprindo pena que lhe fora anteriormente imposta quando voltou a delinquir, devendo incidir, por conseguinte, a agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, inc. I, e art. 63), múltipla na hipótese.

Embora em juízo o réu tenha negado a intenção de traficância, sua confissão informal aos guardas municipais, bem como à autoridade policial, a respeito da destinação das drogas apreendidas em seu poder foi sopesada como importante elemento de convicção, o que deve importar no reconhecimento da atenuante correspondente (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd') nos termos do entendimento jurisprudencial (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).

Deve ser aplicado à hipótese o entendimento do STJ, firmado em julgamento de tese sob o rito dos recursos repetitivos, de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (Tema 585).

Feitas essas considerações, compensada uma das reincidências com a atenuante de confissão, elevam-se as penas de um quarto, a 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

A reincidência do réu impede, objetivamente, a aplicação da causa especial de diminuição de penas preconizada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à hipótese, não havendo causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de penas a considerar, as quais são tornadas definitivas nos patamares em que arbitradas.

Reincidente o réu e aplicada pena privativa de liberdade de prazo superior a quatro anos, incabível sua substituição por pena restritiva de direitos, além da medida não se mostrar suficiente para a adequada repressão e prevenção de condutas similares, nem socialmente recomendável (Código Penal, art. 44, incisos I, II e III, e § 3º).

A quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, aliados ao fato de que cumpria pena em regime aberto quando voltou a delinquir, impõem - a contrário senso do disposto no Código Penal, art. 33, § 2º, 'b' - a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, e isso a despeito de eventual análise da detração da pena (Código de Processo Penal, art. 387, § 2º), pois não importa em alteração do entendimento sobre a premência de fixação de regime mais rigoroso.

Ausentes informes específicos sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60, e Lei nº 11.343/06, art. 43), o valor unitário do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião de acordo com os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Como efeito desta sentença condenatória determino a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido em poder do réu, porque não se comprovou tenha origem lícita, devendo ser considerado produto do narcotráfico (Código Penal, art. 91, inc. II, 'b', e Lei nº 11.343/06, art. 63, inc. I).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Heberton

Luiz do Prado à pena privativa de liberdade de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 625 dias-multa, com cálculo da unidade destes no piso legal, por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º), não sendo caso de suspensão da respectiva exigibilidade uma vez que nesta fase de conhecimento não houve pedido de gratuidade da justiça e a hipossuficiência financeira não é presumível tão só em face da assistência jurídica pela Defensoria Pública do Estado.

O réu foi preso em flagrante e permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo, remanescendo inalteradas as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Está sendo condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade de considerável extensão, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, havendo fundado temor de que busque eximir-se de sua responsabilização caso seja colocado em liberdade neste momento processual. Além disso, é reincidente e cumpria pena em regime mais brando, anteriormente imposta, quando voltou a delinquir.

Não se mostrando adequada, nem suficiente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, determino a manutenção da medida constritiva de liberdade que anteriormente lhe foi imposta.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, oficiando-se.

Ao trânsito em julgado, além das providências de praxe, oficie-se à Senad, encaminhando-lhe informação sobre o valor de R\$20,00, declarado perdido em favor da União (Lei nº 11.343/06, art. 63, §4º), objeto do auto de fls. 15.

Publique-se. Intimem-se.

Taubaté, 08 de julho de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballestero
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA